

AÇÃO PENAL 1.011 SANTA CATARINA

RELATOR	: MIN. GILMAR MENDES
REVISOR	: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S)	: MARIO ROBERTO CAVALLAZZI
ADV.(A/S)	: FRANCISCO EMMANUEL CAMPOS FERREIRA E OUTRO(A/S)
RÉU(É)(S)	: ALINE AZEREDO GARCIA CUSTÓDIO
ADV.(A/S)	: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
RÉU(É)(S)	: DARIO ELIAS BERGER
ADV.(A/S)	: NILTON JOAO DE MACEDO MACHADO E OUTRO(A/S)

DECISÃO: O Ministério Público de Santa Catarina ofereceu denúncia contra Dário Elias Berger, pela prática dos crimes previstos nos arts. 89, *caput* e parágrafo único, e 90 da Lei 8.666/93, combinado com art. 29 do Código Penal, e do art. 1º, XI, do Decreto-Lei 201/67, na forma do art. 13, § 2º, do CP (comissão por omissão); e Mário Roberto Cavallazzi e Aline Azeredo Garcia Custódio, pela prática dos crimes previstos nos arts. 89, parágrafo único, e 90 da Lei 8.666/93.

Narrou a denúncia que, em fevereiro de 2006, Mário Roberto Cavallazzi, Secretário Municipal de Turismo de Florianópolis, e Aline Azeredo Garcia Custódio, representante legal da pessoa jurídica Palcosul Eventos Ltda., frustraram, mediante combinação, o caráter competitivo da Tomada de Preços 55/2006, que tinha por objeto a contratação dos serviços de montagem de camarotes na Passarela do Samba para o carnaval daquele ano. O denunciado Dário Elias Berger, Prefeito Municipal de Florianópolis/SC, teria deixado de se desincumbir do dever de cuidado e da *“obrigação de se evitar que a pessoa de sua confiança (secretário) agisse contrário à Lei”*.

Outrossim, em 11.1.2008, Mário Roberto Cavallazzi, Secretário Municipal de Turismo de Florianópolis, teria dispensado a licitação para a contratação de serviços de montagem de camarotes para o carnaval de 2008, contratando a Palcosul Eventos Ltda., representada pela denunciada

Aline Azeredo Garcia Custódio, a qual concorreu para a consumação do delito. O denunciado Dário Elias Berger, Prefeito Municipal, teria concorrido para o delito, autorizando a dispensa da licitação.

Distribuídos os autos à 2ª Vara Criminal de Florianópolis/SC, foram autuados sob o nº 0910261-33.2013.8.24.0023.

Foi adotado o rito comum ordinário e a denúncia recebida em **11.4.2014**.

Mário Roberto Cavallazzi ofereceu resposta (fls. 704-706). Arguiu a prescrição quanto ao delito do art. 90 da Lei 8.666/93.

Foi pronunciada a prescrição com relação ao crime do art. 90 da Lei 8.666/93. (fls. 731-732)

Tendo em vista a diplomação do denunciado Dário Elias Berger como senador, foi declinada a competência para esta Corte. (fls. 747-749)

O Procurador-Geral da República opinou pelo reconhecimento da prescrição em relação ao crime do art. 1º, XI, do Decreto-Lei 201/67, pela cisão da ação penal, em relação aos denunciados sem prerrogativa de foro, e pela notificação de Dário Elias Berger para oferecer resposta à acusação. (fls. 774-779)

O denunciado Dário Elias Berger constituiu advogado e ofereceu razões escritas (fls. 792-796). Arguiu a inépcia da denúncia, por não descrever sua contribuição para os delitos. Negou a autoria dos crimes.

A denunciada Aline Azeredo Garcia Custódio não foi citada, porque foi localizada em seu endereço conhecido. (fls. 728 e 805v)

Decido.

A denúncia imputou três crimes: (i) arts. 89, *caput* e parágrafo único, e (ii) 90 da Lei 8.666/93, e (iii) art. 1º, XI, do Decreto-Lei 201/67.

Foi pronunciada a prescrição quanto ao crime do art. 90 da Lei 8.666/93. (fls. 731-732)

Dessa feita, o Procurador-Geral da República opinou pelo reconhecimento da prescrição em relação ao crime do art. 1º, XI, do Decreto-Lei 201/67. O máximo da pena privativa de liberdade cominada para o delito é de três anos, conforme o art. 1º, § 1º, do Decreto-Lei 201/67.

AP 1011 / SC

O prazo prescricional é de oito anos, na forma do art. 109, IV, do CP. O fato teria ocorrido em 14.2.2006. A denúncia foi recebida após o decurso do prazo prescricional. Operou-se a prescrição.

Resta apreciar a imputação do crime de dispensa indevida de licitação, art. 89, *caput* e parágrafo único, da Lei 8.666/93, cuja redação transcrevo:

“Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:

Pena – detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público”.

Se a competência é declinada à Corte após o recebimento da denúncia, mas antes da análise da resposta à acusação, na forma do art. 397 do CPP, a apreciação da defesa deve ser realizada no Tribunal. Cito, a propósito, a AP 630 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 15.12.2011.

Passo a apreciar a resposta à acusação deduzida pelo Senador Dário Elias Berger.

A acusação é de que, em 11.1.2008, Mário Roberto Cavallazzi, Secretário Municipal de Turismo de Florianópolis, teria dispensado a licitação, para a contratação de serviços de montagem de camarotes para o carnaval de 2008, contratando a Palcosul Eventos Ltda., representada pela denunciada Aline Azeredo Garcia Custódio, a qual concorreu para a consumação do delito. O denunciado Dário Elias Berger, prefeito municipal, teria concorrido para o delito, autorizando a dispensa da licitação.

O denunciado arguiu a inépcia da denúncia, por não descrever sua contribuição para os delitos.

Conforme art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve

conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”.

No caso, a denúncia apontou a responsabilidade do então Prefeito municipal amparada em “violação a dever de cuidado”, consistente na obrigação de verificar os atos dos demais membros da administração.

O problema da acusação não está no defeito formal da citada peça, a qual descreveu aquilo que entende ser a participação do então mandatário. Ainda que essa descrição não corresponda à conduta típica, a acusação pode ser corretamente compreendida.

Não vislumbro inépcia a ser pronunciada.

Entretanto, não há justa causa para a ação penal, tendo em vista a ausência de prova suficiente da existência do fato.

A jurisprudência interpreta o art. 89 da Lei 8.666/93 no sentido de exigir o prejuízo ao erário e a finalidade específica de favorecimento indevido como necessários à adequação típica. Nesse sentido, o Inq 2.616, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 29.5.2014.

O objetivo desse entendimento é separar os casos em que a dispensa buscou favorecimento indevido daqueles em que ela decorreu de interpretação equivocada das normas, ou mesmo puro e simples erro do administrador.

No caso concreto, não há indicativos de favorecimento indevido ou de prejuízo ao erário.

A dispensa de licitação foi decidida no PL 16/2008, com base no art. 24, IV, da Lei 8.666/93 (emergência). (fls. 21-29)

A fundamentação esclarece que a construção dos camarotes, frisas e arquibancadas na passarela do samba “Nego Quirido” fora contratada com a empresa de construção civil. Essa informação é confirmada pelo Contrato 495/SMO/2007. (fls. 226-244)

Entretanto, o Secretário de Obras informou que as obras não ficariam prontas para o Carnaval de 2008, em decorrência de imprevistos meteorológicos e outros incidentes no curso da construção. De fato, essas informações foram prestadas pelo Secretário de Obras ao Secretário de Turismo, Cultura e Esportes, via Ofício 1138/SMO/2007, datado de 26.12.2007.

Em 11.1.2008, o Secretário de Turismo, Cultura e Esportes optou por contratar empresa para realizar a instalação e remoção de arquibancadas móveis.

A decisão foi precedida de orçamento realizado pela empresa que prestara o serviço no ano anterior, a Palcosul. A justificativa ressaltou que o valor orçado – R\$ 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais) – seria, em grande parte, amortizado pela venda de ingressos para o desfile.

Ressalto que, no ano anterior (2007), tal serviço fora licitado (fls. 96-110). Ao que se sabe, a Palcosul fora a vencedora. Não há dados sobre o valor da contratação. Entretanto, o edital menciona o valor máximo de R\$ 372.000,00 (trezentos e setenta e dois mil reais).

Ou seja, a nova contratação custou pouco mais de 6% (seis por cento), mais do que o valor máximo de contratação do ano anterior.

Aparentemente, os preços são compatíveis com o mercado.

Não há nenhum indicativo de favorecimento a pessoas ligadas à contratada ou de oferta de vantagens indevidas aos agentes públicos.

Pode-se contestar o fato de a contratação ter sido enquadrada como de emergência, na forma do art. 24, IV, da Lei 8.666/93. Mas não há indicativos da presença dos outros elementos necessários à configuração da relevância penal do fato – prejuízo ao erário ou favorecimento pessoal.

Além disso, o feito foi remetido ao STF, tendo em vista que o denunciado Dário Elias Berger é Senador da República.

Ainda que prova de delito houvesse, não existiriam indícios de autoria em desfavor do parlamentar.

A jurisprudência da Segunda Turma do STF é no sentido de que inexistente justa causa para a ação penal por crimes da lei de licitações, em relação ao administrador público que apenas aprova as contratações, sem interferir pessoalmente nas decisões. Confira-se o Inq 3.731, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 2.2.2016. No caso concreto, não há nenhum indicativo de participação do hoje Senador na contratação em questão.

Dario Elias Berger era, na época dos fatos, Prefeito de Florianópolis.

A decisão de dispensar a licitação foi tomada em despacho fundamentado do então secretário municipal Mário Roberto Cavallazzi (fls. 21-29). O Secretário assinou também o contrato administrativo (fls. 32-37) e seu aditamento (fl. 137).

O então Prefeito não tomou nenhuma decisão sobre a contratação. A sua única assinatura, constante do processo administrativo, foi em documento conferindo autorização para a contratação do serviço de “*empresa para a montagem e desmontagem de camarotes*”, mas para o carnaval de 2007. Nesse ano, como já relatado, a contratação foi licitada.

Também não há elementos que levem a crer que o Prefeito tenha influenciado, ainda que informalmente, a decisão.

Indo além, o contrato, considerada a dimensão da administração de Florianópolis, é de valor modesto.

Por fim, não há nenhum indicativo de que o Prefeito tenha sido favorecido pelo contrato ou de sua ligação, direta ou indireta, com a contratada.

Dessa forma, em relação ao denunciado Dário Elias Berger, falta justa causa também pela insuficiência dos indícios de autoria.

Ante o exposto:

(i) pronuncio a prescrição da pretensão punitiva quanto à acusação da prática do delito do art. 1º, XI, do Decreto-Lei 201/67, na forma do art. 109, IV, do CP, extinguindo a punibilidade, na forma do art. 397, IV, do CPP;

(ii) rejeito a denúncia, no tocante à acusação da prática do crime do art. 89, *caput* e parágrafo único, da Lei 8.666/93, extinguindo a ação penal, na forma do art. 395, III, do CPP.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Brasília, 18 de agosto de 2017.

Ministro **GILMAR MENDES**

Relator

Documento assinado digitalmente